

刑事訴訟法第328条にいう「公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うため」に用いることのできる同法「第321条乃至第324条の規定により証拠とすることができない書面又は供述」の範囲については、

- ① 供述をした者の異なった内容の供述を記載した書面又は供述に限定されると解する説
- ② ①のみに限定されないが、それ以外は、供述の信用性のみに関する純粹の補助事実、例えば供述者の能力及び性格、当事者に対する偏見、当事者との間の利害関係等を立証する証拠に限られると解する説
- ③ 伝聞証拠でも、限定なく証拠とすることができると解する説

がある。①から③までの各説に立った場合に、次のアからオまでの【事例】中のAの供述が同法第328条により証拠とすることができるか否かに関する後記aからeまでの【記述】につき、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

- ア. 犯人を目撃した証人Wの「自分が目撃した犯人は白いシャツを着ていた。」旨の証言に対し、Wとともに犯人を目撃したAの「犯人は黒いシャツを着ていた。」旨の司法警察員に対する供述調査により、Wの証言の証明力を争うこと
- イ. 犯人を目撃した証人Wの「被告人甲が犯行現場でVの胸をナイフで突き刺すのを見た。」旨の証言に対し、証人Aの「Wは、『犯行現場には行ったこともないし、甲の殺害行為を見たこともない。』と言っていた。」旨の証言により、Wの証言の証明力を争うこと
- ウ. 犯人を目撃した証人Wの「自分の目撃した犯人は被告人甲とは違う人間である。」旨の証言に対し、Wの友人Aの「Wは、『甲は、自分が経済的に困窮していたとき、生活費を出してくれるなど何かと面倒を見てくれた。』と言っていた。」旨の証言により、Wの証言の証明力を争うこと
- エ. 犯人を目撃した証人Aの「犯人は被告人乙である。」旨の証言が、Aの司法警察員に対する「犯人が被告人乙だとは断言できない。」旨の供述調査によって証明力が減殺された場合、証言内容と一致する内容のAの他の供述調査により、減殺された証明力を回復すること
- オ. 鑑定人Bの「被害者の死因は窒息死である。」旨の供述に対し、「Bが解剖時に『被害者の死因は心筋こうそくの可能性もある。』と述べた。」旨の解剖に立ち会ったBの助手Aの証言により、Bの供述の証明力を争うこと

【記述】

- a. アは、①から③までのいずれの説を採っても、証拠として許容される。
- b. イは、①から③までのいずれの説を採っても、証拠として許容される。
- c. ウは、③説のみならず、②説によっても、証拠として許容される。
- d. エは、③の説を採った場合でなければ、証拠として許容されることはない。
- e. オは、③の説を採った場合でなければ、証拠として許容されることはない。

328 条は、「第 321 条乃至第 324 条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であっても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。」と規定する。本条については、(1)「証明力を争うため」の証拠の範囲、(2)「証明力を争う」の意味、(3)法廷外供述の獲得時期などが主な論点である。本問では、主に(1)の論点が問われていると考えられる。そして、本問に挙げられている①は限定説（最判平 18.11.7、百選 85 事件）、②は補助事実説、③は非限定説と呼ばれる学説である。

a 誤っている

アの事例においては、Wの「自分が目撃した犯人は白いシャツを着ていた。」旨の目撃証言の証明力をAの「犯人は黒いシャツを着ていた。」旨の司法警察員に対する供述調書によって争おうとしている。①限定説によると、目撃証言はWがしているのに対し、供述調書の内容はAの供述である。よって、①限定説からは証明力を争う証拠として許容されない。②補助事実説によっても、①限定説で認められる以外の証拠は、供述の信用性のみに関する純粹の補助事実を立証する証拠についてのみ認められるので、証明力を争う証拠として許容されない。③非限定説によると、Wの供述に対して、W以外の者の供述調書も証明力を争う証拠として許容される。以上より、アは、①から③までのいずれの説を採用しても、証拠として許容されるとしている本記述は誤っている。

b 正しい ★

イの事例においては、Wの「被告人甲が犯行現場でVの胸をナイフで突き刺すのを見た。」旨の目撃証言の証明力をAの「Wは、『犯行現場には行ったこともないし、甲の殺害行為を見たこともない。』と言っていた。」旨の証言によって争おうとしている。①限定説によると、Wの目撃証言に対して、AがWの自己矛盾供述の存在を証言しているので、証明力を争う証拠として許容される。①限定説からは、328 条は、自己矛盾供述をしている事実をもって、その者の供述の信用性を減殺することができるという当然のことを規定したものであり、前後矛盾する供述の内容のいずれが真実に合致するかを問わないのであって、それゆえに、前後矛盾する供述が存在すること自体が要証事実であるから、伝聞法則の適用を受けない一場面であると理解されている。よって、AがWの目撃証言と矛盾するWの供述の存在を証言している以上、証明力を争う証拠として、許容される。なお、②補助事実説及び③非限定説は、①限定説が許容する証拠を含むので、両説からも証明力を争う証拠として許容される。以上より、イは、①から③までのいずれの説を採用しても、証拠として許容されるとする本記述は正しい。

c 正しい

ウの事例においては、Wの「自分の目撃した犯人は被告人甲とは違う人間である。」旨の目撃証言の証明力をAの「Wは、『甲は、自分が経済的に困窮していたとき、生活費を出してくれるなど何かと面倒を見てくれた。』と言っていた。」旨の証言によって争おうとしている。①限定説によると、一方はWの証言であり、他方もAの証言内容はWの供述である。しかし、①限定説からは、自己矛盾供述しか証明力を争う証拠として許容されないものであるから、供述内容が矛盾していないウの事例においては、証明力を争う証拠として許容されない。②補助事実説によると、Aの証言内容であるWの供述内容は、Wが被告人甲から援助を受けたことがあるという内容であり、当事者との間の利害関係等を立証する証拠といえ、証明力を争う証拠として許容される。③非限定説からも証明力を争う証拠として許容される。以上より、ウは、③説のみならず、②説によっても、証拠として許容されるとする本記述は正しい。

d 誤っている

エの事例においては、Aの「犯人は被告人乙である。」旨の証言が滅殺された後に当初の証言内容と一致する他のAの供述調書によって、滅殺された証明力を回復しようとしている。いわゆる回復証拠の提出の可否の問題である。この論点は、前述の(2)「証明力を争う」の意味とも関わる。回復証拠の場合、一致供述の存在それ自体が示されればよく、内容をなす事実の真実性は問題とならないことを理由に、回復証拠の提出を肯定するのが多数説である。①限定説によると、限定した理由が伝聞禁止の趣旨にあることからして、本条の回復証拠についても、元の供述者の、同一内容の供述（一致供述）に限定することになる。エの事例については、Aの他の供述調書が回復証拠となっており、証明力を争う証拠として許容される。②補助事実説及び③非限定説からも、同一人の一致供述による回復を含みうることは、ほぼ見解の一致があり、証明力を争う証拠として許容される。以上より、エは、③の説を採った場合でなければ、証拠として許容されることはないとしている本記述は誤っている。

e 誤っている

オの事例においては、鑑定人Bの「被害者の死因は窒息死である。」旨の供述の証明力を「Bが解剖時に『被害者の死因は心筋こうそくの可能性もある。』と述べた。」旨の解剖に立ち会ったBの助手Aの証言により争おうとしている。①限定説によると、Bの供述とBの供述を内容とするAの証言とで、死因が異なる可能性があるとする点で自己矛盾供述とも考えうる。よって、自己矛盾供述と考えれば、①限定説によっても、証明力を争う証拠として許容されうる。なお、自己矛盾供述といえなくとも、後述のように②補助事実説によっても、証明力を争う証拠として許容されるので、結論に影響はない。②補助事実説によると、Bの自己矛盾供述といえれば、①限定説と同様に証明力を争う証拠として許容される。また、自己矛盾供述ではないと考えた場合にも、Bが死因を窒息死なのか心筋こうそくなのか判断する能力に欠けているという点で供述者の能力に関する補助事実を立証する証拠と考えられ、証明力を争う証拠として許容される。③非限定説によっても、証明力を争う証拠として許容される。以上より、オは、③の説を採った場合でなければ、証拠として許容されることはないとしている本記述は誤っている。

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------